

1502322-67.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas. A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502322-67.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502322-67.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

DIEGO GUSTAVO GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 9 de setembro de 2022, em horário incerto, na Rua Milto Domingo nº 46, Vista Alegre, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo e guardava, para fins de comércio, 76 porções de maconha e 150 porções de cocaína, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares realizavam operação

para coibir o tráfico de drogas na região, quando, no endereço acima mencionado, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, depararam-se com o acusado, que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga em desabalada carreira e jogou uma mochila ao solo.

O réu acabou perseguido e interceptado. Em revista pessoal, os milicianos apreenderam, em poder dele, a quantia de R\$ 114,00. No interior da mochila jogada por ele ao chão, foram encontradas as porções de maconha e cocaína.

Assim, pela quantidade das substâncias entorpecentes e circunstâncias das apreensões, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a Promotora de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do patamar legal, tendo em vista a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, bem como os maus antecedentes do réu; não aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial fechado.

A defesa, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Para tanto, alegou que os depoimentos dos policiais são contraditórios e não merecem crédito, ante o interesse que tem em justificar sua conduta. Em caso de entendimento diverso, requereu o que segue: fixação da pena-base no patamar legal; aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo; imposição de regime inicial aberto, considerando-se o tempo de prisão provisória e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

Diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 14/16 e 62/64), provisório e definitivo, os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a traficância, dizendo que estava no local para comprar drogas, pois era usuário de cocaína. Correu porque o traficante correu também. Os policiais exigiram a quantia de R\$ 2.000,00 para não "forjarem" que a droga de sua propriedade. Não conhecia os policiais e nada tinha contra eles.

Sucedendo que tal negativa restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Com efeito, as testemunhas Hegen Henrique da Silva Oliveira e Rodrigo Aparecido Cardo Alves, policiais militares que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu a prisão do acusado e o encontro das substâncias tóxicas no interior da mochila arremessada por ele ao solo. Reataram, ainda, que foi encontrada certa quantia em dinheiro em poder do réu. Não conheciam Diego antes dos fatos.

E as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação.

Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados que não conheciam, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Celso de Mello DJU 11/04/97).

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (cf. tese nº 06, edição n.º 105 Jurisprudência em teses).

E mais, "(...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura 6ª Turma, DJe 1.6.2011).

Examinando os erros, as incoerências e as contradições de vítimas e testemunhas, pontifica o clássico Borges da Rosa: "Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FRAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas" (v. Borges da Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª ed., RT, 1982, pág. 322).

"O testemunho demasiado perfeito é que deve gerar desconfiança" (cf. Almeida Júnior, Lições de Medicina Legal, pág. 526).

Assim sendo, as pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das testemunhas não lhes retiram o valor probatório.

Como se vê, o conjunto probatório amalhado aos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória, posto que evidenciado o intuito de mercancia.

Para tanto, deve ser ressaltado as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas e como se deu a prisão do agente.

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Ensina Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a

destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, nº 5, pág. 96).

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu DIEGO GUSTAVO GOMES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, no percentual de 1/6 (um sexto), somando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante os maus antecedentes do acusado (fls. 81/82).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Possível a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a jurisprudência mais recente dos Tribunais superiores, motivo pelo qual reduzo a sanção de 1/2 (metade), resultando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

A sanção privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime semiaberto. Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" tem-se que o regime inicial semiaberto é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

Inaplicável o instituto da detração penal ao réu, conforme dispõe a Lei nº 12.736/12, ante as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente e, ainda, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.

Ao incluir o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogou o artigo 33, § 3º, do Código Penal, nem tampouco o artigo 59, inciso III, do mesmo Códex.

E, no caso concreto, as circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis para a fixação de regime inicial menos gravoso.

Assim, não obstante o previsto no artigo 387, § 2º, da Lei nº 12.736/2021 e, "data vênia" dos entendimentos contrários, bem como sendo impossível a este Juízo sopesar a presença dos requisitos subjetivos, incabível a aplicação da detração penal.

Nesse sentido, "1 - Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. c/c o artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, DJ 10/10/2014).

Incabível, portanto, a detração penal ao sentenciado, cabendo ao Juízo da Execução a sua aplicação.

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Assim, fica o réu DIEGO GUSTAVO GOMES, condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 22 de novembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito